

1501241-72.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... sem autorização e para fins de tráfico, um total de 793,600g de maconha, substância entorpecente e que causa dependência física e/ou psíquica, bem como apreenderam em poder deles a quantia total de R\$ 61,00 em dinheiro, produto do narcotráfico, e petrechos para o tráfico. Narra a denúncia que os acusados se associaram para o fim de praticar o tráfico de drogas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, ., Centro - CEP 15010-400, Fone: (17)

3233-6700, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - SESSÃO VIRTUAL - COMUNICADO
CG Nº 284/2020

Processo Digital nº:

1501241-72.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2232312/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 19859841 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 4810/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2232312 - 03º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 4810/21/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS MENDES e outro

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Justiça Gratuita

Em 11 de maio de 2022, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto-SP, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de Instrução Debates e Julgamento, nos autos do processo em epígrafe, da 1ª Vara Criminal desta Comarca, realizada excepcionalmente por videoconferência, através da ferramenta "Microsoft Teams", tendo em vista a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov), o que levou à adoção, por este E. Tribunal de Justiça, de procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo

Coronavírus, bem para o retorno escalonado e gradual das atividades presenciais, estabelecidos pelos Provimentos CSM nº 2545, 2549, 2561 e 2464/2020. Cumpridas as formalidades de praxe, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, verificou-se presentes o digno representante do Ministério Público, Exmo. Sr. Dr. SÉRGIO ACAYABA DE TOLEDO, o(a) acusado(a) MATHEUS MENDES, bem como seu Defensor: o Exmo Sr. Dr. LUIZ EDUARDO KAWANO DIAS, d. Defensor Público atuante nesta Vara; presente o acusado EDUARDO POIATE DE MELLO, bem como seu(ua) defensor(a): RENATO REZENDE CAOS, OAB 295950/SP (const. fls. 145) e, aguardando no lobby, estava(m) a(s) testemunha(s) comuns MARCELO AUGUSTO LOURENÇO, e CESAR ROBERTO TEIXEIRA JÚNIOR, e as testemunhas da defesa RICARDO SILVA GONÇALVES, VITÓRIA ALINE COELHO DA SILVA, e AMANDA PARO BONFATE; instalou-se a audiência. As partes ficam cientificadas que o termo de audiência será assinado eletronicamente pelo Juiz, bem como que eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas no momento da realização do ato, sob pena de preclusão (artigo 1269/1270 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça). Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados pelo sistema audiovisual, através da ferramenta "Microsoft Teams". Será disponibilizada a gravação da audiência em sua integridade, ficando vinculada neste termo de audiência, e em um eventual recurso, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020, estará disponível no E-SAJ. A seguir, acomodadas as partes, o(a) MM. Juiz(a) procedeu à inquirição da(s) testemunha(s) MARCELO (00min33seg), CÉSAR (03min48seg), RICARDO (07min03seg), VITÓRIA (09min15seg), e AMANDA (10min38seg), bem como, respeitado o item 8.1 do Comunicado CG nº 284/2020, procedeu ao interrogatório do(s) acusado(s) MATHEUS (12min47seg), e EDUARDO (20min43seg), colhidos pelo sistema audiovisual, através do aplicativo "Microsoft Teams", e tendo em vista não haver mais provas a serem produzidas, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução criminal e determinado que se passasse aos debates orais, tendo as alegações finais da acusação (31min59seg) e, respectivamente, da defesa dos acusados MATHEUS (40min56seg), e EDUARDO (46min01seg) sido gravadas em audiovisual. Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. MATHEUS MENDES e EDUARDO POIATE DE MELLO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narra a denúncia, no dia 25 de agosto de 2021, por volta das 16 horas, no cruzamento da Rua José Maceno com a Rua Bernardino de Campos, e na residência situada à Rua Iriritiba, 265, no bairro Vila Anchieta, nesta cidade, os acusados, ambos menores de 21 anos de idade, devidamente associados, foram surpreendidos por policiais militares transportando na motocicleta marca Honda, modelo CG 125 Today, ano 1994, cor preta, placa BVE-6520/Nipoã-SP, e mantendo em depósito, sem autorização e para fins de tráfico, um total de 793,600g de maconha, substância entorpecente e que causa dependência física e/ou psíquica, bem como apreenderam em poder deles a quantia total de R\$ 61,00 em dinheiro, produto do narcotráfico, e petrechos para o tráfico. Narra a denúncia que os acusados se associaram para o fim de praticar o tráfico de drogas, tendo adquirido, juntos, R\$ 400,00 em maconha, sendo que cada um pagou R\$ 200,00 pela droga, a qual era destinada à venda, e a guardaram na residência de EDUARDO. Narra que na data dos fatos, após negociarem a venda de três porções de maconha, fracionaram a droga e se dirigiram até o endereço combinado com o comprador (Centro Poliesportivo Júpiter Olímpico) utilizando a motocicleta acima descrita, pilotada por MATHEUS e tendo EDUARDO como garupa, quando acabaram se envolvendo em um acidente, danificando a moto e fazendo com que tivessem que empurrá-la. Enquanto empurravam a motocicleta uma viatura policial passou por eles, os quais, devido à atividade ilícita que praticavam, ficaram nervosos, gerando suspeita e culminando nas suas abordagens, sendo que em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com MATHEUS, mas com EDUARDO, em sua mão, encontraram uma porção pequena de maconha envolta em plástico filme, e no cós da sua cueca foram encontradas mais duas porções de maconha. Narra que no bolso de EDUARDO ainda foram encontrados a quantia de R\$ 9,00 em dinheiro e um aparelho celular marca Motorola com a tela danificada. Indagados, os dois confessaram informalmente que tinham adquirido R\$ 400,00 em maconha juntos, para revender,

sendo que quando estavam no caminho para entregar as três porções de maconha ao comprador, e ainda acrescentaram que o restante da droga estava na residência de EDUARDO, tendo os policiais se dirigido ao imóvel, onde, com a autorização por escrito, ingressaram e encontraram uma porção mediana de maconha na geladeira. No quarto de EDUARDO, embaixo da cama box, encontraram mais três porções medianas de maconha, uma faca e uma balança digital com resquícios da droga, além de R\$ 52,00. Notificados (fls. 151 e 153), os acusados apresentaram resposta à acusação (fls. 140/144 e 222/227). Recebida a denúncia (fls. 236/239), foram citados. Durante a instrução, depois de ouvidas as testemunhas, os acusados foram interrogados. A instrução foi encerrada e nos debates orais o Ministério Público reiterou o pedido condenatório contido na denúncia, ao passo que a Defesa sustenta a absolvição, alegando, em suma, falta de provas. É o relatório. DECIDO. No auto de prisão em flagrante o acusado MATHEUS afirmou que estava conduzindo a motocicleta, levando na garupa seu colega Eduardo, quando foram até o bairro Santo Antônio comprar maconha. Compraram a quantia de R\$ 400,00 de maconha, sendo que cada um deu R\$ 200,00. A compra dessa droga se deu para o seu próprio uso e também para o uso do seu colega. Depois, já com a droga, estavam indo até o Júpiter para fumar, mas no trajeto acabou colidindo na moto de outro rapaz, sendo que naquele momento surgiu uma viatura do Baep e foram abordados. Indicou que em razão da colisão o interrogando caiu, sendo que parte da maconha ficou no chão e seu colega segurou. Foram indagados se mantinham droga em suas casas, mas negou. Uma viatura foi até sua casa, onde estava sua avó. Não acompanhou as buscas, permanecendo na viatura. Nada de ilícito foi localizado em sua casa. Confirmou que os policiais foram até a casa de Eduardo, não sabendo se eles encontraram algo ilícito no local. Negou ser traficante, mas apenas usuário. Em Juízo o acusado MATHEUS negou a prática dos crimes que lhe são imputados, dizendo que o Eduardo o chamou para juntos consumirem maconha. A moto lhe pertencia, saindo de sua casa, depois passando na residência do corréu Eduardo e estavam indo para o Júpiter Olímpico para juntos consumirem a droga quando foram abordados pela polícia. Não sabia que havia mais drogas na casa do Eduardo e não tinha qualquer participação na droga apreendida na residência daquele. É usuário de drogas desde os 11 anos de idade. Conheceu o réu Eduardo há cerca de 4 meses. Trabalhava como servente de pedreiro. Não é verdade que adquiriram maconha juntos. Quando adolescente teve passagens por ato infracional equiparado por tráfico e ficou internado na Fundação Casa. Na fase extrajudicial o acusado EDUARDO confirmou que foi com o amigo Matheus até o bairro Santo Antônio para comprar maconha, pois ambos são usuários. Foi na garupa da moto. Adquiriam R\$ 400,00 em maconha, sendo que cada um deu a metade. É usuário desde os 11 anos de idade. Compra quantidade maior porque usa bastante e também faz uso de remédio controlado. Não consegue ficar sem fumar maconha e sem tomar os remédios. O interrogando ficou segurando a droga porque Matheus estava dirigindo. Resolveram fumar maconha no Júpiter, mas durante o trajeto Matheus foi atingido por um motoqueiro, momento em que passava pelo local uma viatura do Baep. Ambos caíram no chão por conta da colisão com a moto e sofreram ferimentos leves. Foram abordados pelos policiais e em seu poder apreenderam a droga, mas frisou que era metade de cada. Inicialmente negou aos policiais que mantivesse mais droga em sua casa, mas depois acabou contando que tinha mais uma porção, justificando que usa muita droga todos os dias. Ficou no local onde foi abordado junto com Matheus e outra viatura foi até sua casa. Entregou a chave da sua casa aos policiais. Em sua casa localizaram o restante da droga indicada, bem como a balança que usa para pesar a droga quando compra, para saber se não foi enganado e também uma faca que usa para cozinhar. Mora sozinho e quem o ajuda é sua mãe. Interrogado em Juízo o acusado novamente negou a prática dos crimes que lhe são imputados, dizendo que as drogas lhe pertenciam e se destinavam ao próprio consumo. Adquiri grande quantidade de maconha porque é usuário crônico de drogas e desde os 11 anos de idade. Já foi internado em clínicas de recuperação. Chamou Matheus para juntos consumirem maconha no Júpiter Olímpico. Matheus

passou em sua casa e no caminho foram abordados pelos policiais. A droga apreendida na sua casa lhe pertencia e o corréu não tinha qualquer participação. Falou para os policiais que era usuário de drogas. Não estava trabalhando e era

sustentado pela mãe, que lhe dava dinheiro para comprar os entorpecentes. Quando adolescente já foi internado na Fundação Casa e pela prática de ato infracional equiparado a tráfico de drogas. Os policiais Marcelo Augusto Lourenço e César Roberto Teixeira Júnior, no auto de prisão em flagrante, afirmaram que durante patrulhamento visualizaram dois indivíduos empurrando uma motocicleta CG de cor preta, placa BVE-6520, e como demonstraram nervosismo, foram abordados. O condutor da motocicleta era o acusado MATHEUS, que foi revistado e nada de ilícito foi localizado. O garupa era o acusado EDUARDO, e em sua mão estava uma porção de "maconha" pequena, envolta em plástico filme, e no cós da cueca encontraram mais duas porções semelhantes de maconha. No bolso de EDUARDO ainda foi encontrado R\$9 e um celular marca Motorola com a tela danificada. Indagados, ambos afirmaram que tinham adquirido R\$ 400,00 de maconha juntos, para revender, sendo que enquanto estavam no caminho para entregar as três porções de maconha no Centro Esportivo Júpiter Olímpico, com a motocicleta de propriedade de MATHEUS, acabaram sofrendo um acidente de trânsito, e por esse motivo estavam empurrando a motocicleta. Ambos ainda disseram que o restante da droga estava na residência de EDUARDO. Assim diligenciaram até a casa de EDUARDO onde, com sua autorização por escrito, adentraram ao local, encontrando uma porção média de maconha na geladeira e no quarto de EDUARDO, debaixo da cama, outras três porções medianas de "maconha", uma faca e uma balança digital com resquícios da droga, além de R\$52. Indicou que a casa de Matheus não foi vistoriada. No mesmo sentido são as declarações dos policiais na fase judicial, reiterando a narrativa acima e acrescentando que não conheciam os acusados. Ricardo Silva Gonçalves não presenciou os fatos, dizendo que conhece o réu Eduardo há muitos anos, informando que ele já foi internado em clínicas para dependentes químicos. Vitória Aline Coelho da Silva e Amanda Paro Bonfante também não presenciaram os fatos, relatando que a mãe do Eduardo já o internou em clínicas em razão do uso de drogas. Ante o exposto, pela prova do feito, angariada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de rigor a condenação. A materialidade é comprovada pelos documentos de fls.1/22 (auto de prisão em flagrante), fls.115/119 e 166/177 (laudos) e pela prova oral. De igual forma a autoria restou comprovada, recaindo no acusado Eduardo, mormente porque a prova dos autos demonstra que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao acusado, se destinavam ao comércio ilícito e não apenas ao consumo próprio, mormente pelas condições da abordagem. Ressaltem-se as narrativas uníssonas e coerentes dos policiais, no sentido de que inicialmente apreenderam parte da droga em poder do corréu Eduardo e depois, contando com a indicação dele, na casa de Eduardo apreenderam o restante da droga, bem como dinheiro e petrechos. Necessário destacar que além da grande quantidade de droga apreendida, para a solução do delito em tela outras circunstâncias são observadas, tais como o local da apreensão, as condições da prisão, a profissão exercida, a forma como estavam embaladas, a apreensão dos petrechos, etc. Vale ressaltar a importância de se aferir o modo de vida dos acusados, no caso, não tendo sido trazidos aos autos elementos que conduzam à certeza quanto à possibilidade de poder incursionar pela seara do uso de drogas. Ademais, não restou comprovada a origem lícita do numerário apreendido. Ressalte-se a apreensão dos petrechos contendo resquícios de entorpecentes (fls. 118/119), inclusive balança de precisão, instrumento reconhecidamente usado em crimes do tipo, não restando dúvidas acerca da verdadeira destinação da droga apreendida. Temos ainda a perícia no celular apreendido com o réu, em que há mensagens e fotos que não deixam dúvidas que atuava no comércio ilícito (fls. 166/170). Além do mais, pode coexistir, na mesma pessoa, a figura de traficante e usuário. O fato de ser usuário de substância entorpecente não obsta ao reconhecimento da figura de traficante. Ao contrário, é natural que ambas as condições, a de usuário e a de traficante coexistam, pois, com a arrecadação obtida com a venda do entorpecente, possibilitar-se-á o emprego na compra, para que o vício possa ser sustentado. Quanto ao valor dos depoimentos de policiais, como são servidores públicos, fielmente compromissados com o bem e a defesa da coletividade (o dever funcional de um policial, em sentido estrito, é prevenir e reprimir o crime), presume-se que agem corretamente e são dignos de credibilidade, mormente porque não há nos autos nenhuma notícia de que teriam motivo para imputar acusação falsa aos réus, que

sequer conheciam. Aliás, como já se decidiu, “Os depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o réu, por tráfico ilícito de entorpecentes, gozam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam as provas testemunhais. Apenas porque são policiais não estão não impedidos de depor, tampouco possuem tais depoimentos pequeno valor, sobretudo se os mesmos estão em harmonia com as demais provas dos autos, inclusive com a delação dos usuários da fase inquisitorial” (TJ-DF, Ap. 20030110632367APR, 1ª T., Rel. Edson Alfredo Smaniotto, 09.03.2006, v.u., DJ 31.05.2006, p. 180). No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. 2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo. 3. Ordem denegada” (STJ, HC 30776/RJ; Ministra Laurita Vaz, j. 03/02/2004, DJ 08.03.2004, p. 304). “Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 - Materialidade delitiva e autoria demonstradas. A forma como ocorreu a apreensão impede a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei. Prova - Palavras de Servidores Públicos - Validade - Inexistência de motivos para incriminarem o réu injustamente. Penas fixadas acima do mínimo legal, em razão da reincidência. Regime prisional fechado. Recurso provido” (TJ-SP, Apelação nº 0010112-19.2016.8.26.0050, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Machado de Andrade, v.u., j. 5 de julho de 2018). Vale ressaltar ainda que para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes basta a ocorrência de um dos verbos do tipo penal (descrição da lei), o que, neste caso, constitui o fato dos réus portarem e armazenarem os entorpecentes apreendidos, com o objetivo de comercializá-los, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por outro lado, no tocante ao corréu MATHEUS a prova se revela frágil. A única prova que o incrimina é abordagem junto com o corréu Eduardo, bem como a confissão informal. É certo que os réus apresentaram versões diferentes quando ouvidos, no entanto, não há prova que confirme que as drogas apreendidas com Eduardo, mormente na residência deste, também lhe pertencia. Com efeito, para condenar é preciso prova incontestada, que conduza à certeza, evidenciando o delito e a sua autoria, pois a dúvida vem em benefício do acusado, prevalecendo o princípio da presunção de inocência. Em uma eventual condenação poder-se-ia correr o risco de condenar inocente. Impõe, pois, a absolvição do réu Matheus, por insuficiência de provas. Quanto ao delito descrito no artigo 35, “caput”, da Lei de Drogas, observo que as provas produzidas não são suficientes para concluir que os acusados estavam associados entre si, reiteradamente ou não, com a finalidade de traficar entorpecentes. Aliás, para a configuração do crime de associação para o tráfico, exige-se pluralidade de agentes, duas ou mais pessoas, ligadas entre si por um animus associativo, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de entorpecentes. No caso, não ficou suficientemente provado que estavam associados a outros indivíduos, para fins de tráfico de drogas. O tipo penal exige “o animus associativo de forma estável e duradora com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo” (STJ - Resp nº 1113728-SC, 5ª T., rel. Felix Fischer, 29.09.2009, v.u.). Assim, ante a falta de provas, a absolvição é medida que se impõe. Passo à dosimetria das penas. Na primeira fase, atendendo aos critérios do art. 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 625 dias-multa, no mínimo a unidade. Para tanto, levo em consideração a quantidade de drogas apreendidas (793,6g de maconha). Na segunda fase incide a atenuante da

menoridade, razão pela qual reduzo as penas em um sexto, resultando em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase descabida a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos legais: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. Ora, neste caso, embora o acusado seja primário, sem antecedentes criminais e não havendo notícia de que integre organização criminosa, pode se afirmar que se dedica a atividades delituosas. Com efeito, a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é destinada somente para os pequenos e iniciantes traficantes, o que não é o caso. O acusado, quando menor de idade, teve diversos processos na Vara da Infância e Juventude, inclusive pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico, tendo sido internado na Fundação Casa (fls. 66/67 e interrogatório judicial). Ressalto que as condutas ilícitas praticadas quando menor, não são maus antecedentes, nem reincidência, mas constatação do envolvimento do réu com o tráfico de drogas, tudo a confirmar que ele não era iniciante na mercancia ilícita. Ademais, não comprovado que exercia atividade lícita. Nesse sentido decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Como é consabido, para a incidência da minorante especial prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos no dispositivo, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa. 3. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp 1560667/SC, Rel. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17/10/2017, DJe 23/10/2017, grifo meu). Não se deve olvidar que além da dedicação a atividades ilícitas desde a adolescência, no celular do acusado havia fotos de drogas, dinheiro e revólver (fls. 166/170), a confirmar a dedicação a atividade ilícitas. Temos ainda a apreensão de petrechos com resquícios de drogas e a apreensão de expressiva quantidade de droga, somente obtida em contato direto com organizações criminosas, o que é notório, trazendo elevado risco à saúde pública, além da mitigação não ser direito subjetivo. Ausentes outras causas de aumento ou diminuição, ficam definitivas as penas acima lançadas. Fixo o regime inicial para o cumprimento da pena de prisão no fechado. Reitero que o acusado foi surpreendido com grande quantidade de drogas e petrechos, de sorte que a gravidade concreta do delito revela-se totalmente incompatível com regimes menos gravosos. Ressalto que a fixação do regime fechado se faz necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos desta natureza e acautelar o meio social. Ademais, a quantidade de droga apreendida justifica o regime mais severo. Nesse sentido, decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE AUMENTO DO INC. III DO ART. 40 E CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (STF, HC 161247/SP, AG.REG. NO HABEAS CORPUS, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 22/02/2019, Órgão Julgador: Segunda Turma, v.u.). "Ementa: REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. MODO MAIS GRAVE JUSTIFICADO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A quantidade de entorpecente apreendido justifica a manutenção do modo prisional mais gravoso, consoante vem decidindo esta Corte Superior de Justiça. 2. Na

espécie, estabelecida a pena em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, proporcional o estabelecimento do regime mais severo, ante a quantidade do entorpecente. Exegese do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em combinação com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravamento regimental desprovido" (STJ, AgRg no HC 458375/SC, AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0168683-8, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, j. 25/06/2019, DJe 02/08/2019). O réu está preso. Nego o direito ao recurso em liberdade. O crime que cometeu e as penas a que está submetido, nesta sentença, são suficientes para retratar sua periculosidade se solto, de modo que a prisão se sustenta na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Ademais, como permaneceu preso durante a tramitação do processo, seria um contrassenso que, sem o primeiro título de condenação, a sentença, houvesse motivo para manutenção do cárcere. E, depois, com a definição da culpa (ou pelo menos a primeira definição rumo à culpa), tivesse o direito de deixar a prisão. Assim, já se decidiu: "Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. (...) Direito de apelar em liberdade. Réu que permaneceu custodiado ao longo do processo. Prisão preventiva. Fundamentação. I - O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva. (Precedentes do STJ e do STF). II - A exigência da prisão provisória para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. (Súmula n. 09 do STJ). (...) III - Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantir ao paciente a revogação da prisão cautela (Precedentes). Writ denegado" (HC 62882/RS; Ministro Felix Fischer, j. 07/11/2006, DJ 12.02.2007, p.285). O presente caso não comporta aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois, com a prisão provisória, ainda não alcançaram o tempo que lhes permitiria a progressão de regime. Ante ao exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, o que faço para condenar o réu EDUARDO POIATE DE MELLO como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 520 dias-multa, no mínimo a unidade. Sem prejuízo, absolvo o corréu MATHEUS MENDES da acusação de cometimento dos crimes do artigo 33, caput e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor. Absolvo também o réu Eduardo da acusação de cometimento do crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Quanto ao réu Eduardo, sem direito a recurso em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontram. Condene-o ainda no pagamento das custas, no valor de 100 UFESPs, observando-se, contudo, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 237). Comprovado o tráfico de drogas, decreto o perdimento do dinheiro, celular e veículo apreendidos, em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06. Com efeito, não foi comprovada a origem lícita dos bens apreendidos e com relação ao veículo basta que seja utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes para a decretação de seu perdimento, como medida desestimuladora da conduta ilícita. Por fim, após o trânsito em julgado desta sentença, comunique-se à Justiça Eleitoral a suspensão dos direitos políticos do réu Eduardo (art. 15, inciso III, da Constituição Federal). Em seguida, o acusado EDUARDO manifestou interesse em RECORRER DA SENTENÇA. Pelo(a) MM Juiz(a) foi dito que recebia o recurso. Nesta oportunidade a defesa sai intimada para o oferecimento das razões de recurso, no prazo legal. Já o acusado Matheus declarou que não deseja recorrer da sentença. Expeça-se o necessário, inclusive guia de recolhimento provisória, se o caso. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se e cumpra-se, oportunamente. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Janete Mayumi Gobara, M358186 - Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): assinado eletronicamente